

1049024-39.2021.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Rescisão / Resolução

Magistrado: Helmer Augusto Toqueton Amaral

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 8ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Segurança do direito e segurança do tráfico de certa maneira colidem (Victor Ehrenberg, Rechtssicherheit und Verkehrssicherheit, Jherings Jahrbücher, 47, 274 s.). A segurança do direito consiste em que se não ponham em dúvida a sua existência e o seu conteúdo. A segurança do tráfico, em que a esperada modificação do estado presente das posições jurídicas de alguma pessoa não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

8ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, 12º andar, sala 1218 - Centro

CEP: 01501-900 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 3538-9107 - E-mail: upj6a10cv@tjsp.jus.br

1049024-39.2021.8.26.0100 - lauda

TERMO DE CONCLUSÃO

Em 18/11/2022, faço estes autos conclusos ao(à) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central. Eu, Carolina Nobrega Zamataro, Assistente Judiciário, Subscrivi.

SENTENÇA

Processo nº:

1049024-39.2021.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Rescisão / Resolução

Requerente:

David Martinez e outro

Requerido:

Melchert Empreendimento Imobiliário Spe Epp

Prioridade Idoso

Vistos.

David Martinez e Miriam Ignatti, qualificados nos autos, ajuizaram a presente ação de rescisão contratual em face de Melchert Empreendimento Imobiliário SPE - EPP, também qualificada. Alegaram em síntese: terem as partes firmado compromisso de compra e venda, com dação em pagamento e outras avenças através do qual a ré se comprometeu a edificar empreendimento imobiliário em imóvel pertencente aos autores, mediante pagamento em dinheiro e em unidades imobiliárias; ter a requerida se obrigado a incluir os autores na SPE constituída, o que não foi empreendido; ter se operado o atraso na entrega da obra; impor-se a rescisão contratual; haver dano moral e material indenizáveis. Pleitearam a procedência. Juntaram documentos. Citada, a ré contestou (fls. 261/295), sustentando em síntese: ser nula a citação; ser a inicial inepta; haver conexão; inexistir o alegado inadimplemento da requerida; terem os requerentes descumprido o contrato, deixando de outorgar escritura pública para transferência do imóvel e de apresentar a documentação necessária para inclusão no quadro societário da SPE; terem as partes aditado o

contrato, tendo a ré realizado o pagamento antecipado, em dinheiro, do valor correspondente a parte das unidades que seriam entregues aos autores; não subsistir o pedido de rescisão. Impugnou o valor da causa e o benefício da gratuidade. Pleiteou a improcedência. Juntou documentos. Houve réplica (fls. 1140/1167). A preliminar de conexão e a impugnação ao valor da causa foram acolhidas (fls. 1169/1170).

Em apenso encontra-se o processo nº 1006132-09.2021.8.26.0006, ação cominatória entre as mesmas partes, com polos invertidos, na qual a Melchert pleiteia a condenação dos réus na obrigação de cumprir o contrato e outorgar a escritura para transferência do imóvel à SPE. Foi apresentada contestação (fls. 517/538) e réplica (fls. 753/777).

É o relatório.

Decido.

Conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC, por se tratar de questão preponderantemente de direito, já se encontrando os autos devidamente instruídos naquilo que diz respeito aos fatos.

Já disse Pontes de Miranda em seu Tratado de Direito Privado:

"A boa-fé é protegida à custa de alguém (e.g., verdadeiro titular); de modo que o direito pesa, aí, respeitáveis interesses. 10. Segurança jurídica. Segurança jurídica, referindo-se à ordem jurídica no sentido subjetivo (não confundir com segurança jurídica no sentido de ordem jurídica, isto é, no sentido objetivo, cf. nosso *Rechtssicherheit und innerliche Ordnung*, *Blätter Jur vergleichende Rechtswissenschaft*, 17, 1 s.), é a segurança, que têm as pessoas, quanto à aquisição, modificação, eficácia e extinção dos direitos, principalmente no trato com as outras pessoas (sem se excluir que a segurança no trato se choque, de algum modo, com a segurança do direito de outros). Donde a antinomia: é preciso que A seja seguro da propriedade que tem; mas também é preciso que C, que adquiriu de B a propriedade de A, registrada em nome de B, seja seguro da sua aquisição. Segurança do direito e segurança do tráfico de certa maneira colidem (Victor Ehrenberg, *Rechtssicherheit und Verkehrssicherheit*, *Jherings Jahrbücher*, 47, 274 s.). A segurança do direito consiste em que se não ponham em dúvida a sua existência e o seu conteúdo. A segurança do tráfico, em que a esperada modificação do estado presente das posições jurídicas de alguma pessoa não seja atingida por circunstâncias que ela ignora. Daí, ter-se de pensar em regras jurídicas que satisfazem a essa, à custa daquela. Uma vez que a segurança do direito é princípio geral e a proteção da boa-fé se veio impor, excepcionalmente, ao legislador, só se atende a ela onde há regra jurídica que a tutela. Não se deve ir além das espécies previstas, a título de interpretação das regras jurídicas especiais. A técnica jurídica legislativa é que cabe marcar os limites da brecha que a segurança do tráfico exige abrir-se à segurança dos direitos" (Tomo I, Capítulo VI, § 44, item 10).

Ainda sobre o tema boa-fé objetiva das relações, o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, em artigo, ensina que a boa-fé, enquanto padrão de conduta leal, não vale apenas para proteção da parte vulnerável, de quem, acrescenta-se, se exige igual comportamento, máxime quando signifique a preservação de valores básicos do sistema, portanto de interesse social, em que se coloca a questão da confiança no trato negocial (in *Revista do Direito do Consumidor*, n. 14, p. 20-27). Ou seja, a boa-fé objetiva evita o exercício inadmissível, contraditório, conflitivo de posições jurídicas, conforme diz Menezes Cordeiro (Da Boa-fé no Direito Civil, Almedina, 1.984, , vol. II, p. 661), a cujo conceito se subsumem hipóteses em que certo comportamento, por suas características, leva à crença de que algum direito subjetivo não venha mais a ser exercido (a denominado *suppressio*, ainda na lição de Menezes Cordeiro, op. cit., p. 797).

A isto deve-se acrescentar importante trecho do voto proferido no RESP 1.202.514-RS, rel Min. Nancy Adrigli:

"Com efeito, a boa-fé objetiva, princípio geral de direito recepcionado pelos arts. 113 e 422 do CC/02 como instrumento de interpretação do negócio jurídico e norma de conduta a ser observada pelas partes contratantes, exige de todos um comportamento condizente com um padrão ético de confiança e lealdade.

A boa-fé objetiva induz deveres assessórios de conduta, impondo às partes comportamentos obrigatórios implicitamente contidos em todos os contratos, a serem observados para que se concretizem as justas expectativas oriundas da própria celebração e execução da avença, mantendo-se o equilíbrio da relação. Essas regras de conduta não se orientam exclusivamente ao cumprimento da obrigação, permeando toda a relação contratual, de modo a viabilizar a satisfação dos interesses globais envolvidos no negócio, sempre tendo em vista a plena realização da sua finalidade social.

Dessarte, o princípio da boa-fé objetiva exercer três funções: (i) instrumento hermenêutico; (ii) fonte de direitos e deveres jurídicos; e (iii) limite ao exercício de direitos subjetivos. A esta última função aplica-se a teoria do adimplemento substancial das obrigações e a teoria dos atos próprios, como meio de rever a amplitude e o alcance dos deveres contratuais, daí derivando os seguintes institutos: tu quoque, venire contra facutm proprium, surrectio e supressio. Para o deslinde da presente controvérsia interessa apenas a supressio, que indica a possibilidade de se considerar suprimida determinada obrigação contratual na hipótese em que o não exercício do direito correspondente, pelo credor, gerar ao devedor a legítima expectativa de que esse não-exercício se prorrogará no tempo. Em outras palavras, haverá redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a sensação válida e plausível - a ser apurada casuisticamente - de ter havido a renúncia àquela prerrogativa".

Tais disposições tem plena aplicação ao caso presente.

Pretendem os autores rescindir contrato de compra e venda, reintegrando-se na posse de imóvel alienado a requerida.

Alegam inadimplemento porque avençado que em razão da venda os promitentes vendedores (autores) receberiam unidades e ingressariam na SPE a ser criada para viabilizar o empreendimento, sendo certo que no entanto não houve tal inclusão. Sustentam que a obra não teve seguimento regular, fazendo jus ao desfazimento do negócio.

Sem razão os requerentes.

Primeiro observo que ao contrário do insinuado, os requerentes não são leigos nem atuaram desassistidos na negociação. Além de empreenderem atividade comercial, sempre foram assistidos por profissional jurídico, certamente vinculado a família do autor diante do sobrenome (Augusto Martinez).

Mais que isso, percebe-se que os requerentes sempre buscaram aquilo que melhor satisfazia seus interesses no momento da negociação, sendo certo que inclusive o aditamento visou certamente atender necessidade de valores para fazer frente a obrigações pendentes com terceiros.

A ausência de ingresso dos requerentes na SPE não tem os contornos buscados.

SPE (Sociedade de Propósito Específico - art. 981, paragrafo único do CC) é criada não para proteger os sócios, mas sim os adquirentes. Através desse modelo de sociedade todos os sócios - e não somente as construtoras envolvidas - respondem igualmente por riscos e problemas que possam ocorrer no andamento do projeto, afetando o patrimônio da SPE, de forma separada de outros empreendimentos.

Ou seja, alegar-se que teria sido retirada garantia pela não inclusão dos requerentes na SPE é argumentação especiosa, sobretudo porque não há nos autos qualquer constituição dos requeridos em mora no tocante a este aspecto, só lembrado para fundamentar o presente pedido de rescisão.

Com efeito, pelo documento de fls. 45, firmado em 23/11/16 as partes convencionaram a venda do imóvel. Em março de 2018 as partes aditaram o contrato em razão do fato da construção não estar se operando no ritmo esperado, tendo sido entregue aos requerentes compensação financeira.

Note-se que não há no aditamento qualquer reclamação dos requerentes por descumprimento relativo a inclusão na SPE, inobstante já superado o prazo para tal, e cientes da fase das obras.

Bom notar ainda que conforme cláusula 2.3 (fls.36) as partes não ajustaram, enquanto contraprestação, qualquer ingresso em sociedade. Pelo contrário, ajustou-se o valor de R\$ 3.600.000,00 pelo imóvel, montante este a ser pago não com cotas

sociais, mas sim com valor em espécie (R\$ 330.000,00) e unidades do futuro empreendimento (itens b1 e b2).

A questão da SPE aparece de forma subliminar, as fls. 37, parágrafo único do item b3 que tratava das dimensões das unidades : "que, após a conclusão da edificação das unidades residenciais objeto da presente dação em pagamento e a convenção e especificação de condomínio com as respectivas matrículas individuais, os PROMITENTES VENDEDORES serão chamados para receberem as escrituras de venda e compra como devolução de cotas de capital e/ou distribuição de lucros, por ocasião do encerramento da empresa SPE da qual constarão como sócios, onde se obrigam desde já em viabilizar todos os documentos e meios necessários pra a transmissão do domínio, sendo certo que a outorga da escritura deverá ocorrer no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da comunicação".

Posteriormente, no parágrafo primeiro do item 2.6 (fls. 38) consta que os autores entregariam escritura definitiva como integralização de capital (conferencia de bens), passando a fazer parte da sociedade, "...até 29 de novembro de 2.016..." (fls.38).

Analisando-se a correspondência (fls.76) percebe-se que a preocupação referente ao ingresso na SPE dizia respeito a questão de tributação. Chegou a ser feito instrumento de conferencia de bens (fls.83). Mas nenhuma informação há nos autos após tal situação sobre integralização de capital.

As mensagens prosseguem com preocupação sobre o retardamento da obra (abril de 2017 - fl.91; agosto de 2017 - fls.93).

Depreende-se dos autos que houve problema com a integralização, esclarecidos ao procurador dos autores, dr. Augusto Martinez já em maio de 2017 (fls.94) , informação esta não trazida aos autos de forma clara quer pelo autor quer pelo réu. E a questão do retardamento foi solucionada com o aditivo de março de 2018, que encerra a discussão trazida pela correspondência de fls.96 e ss. (a qual nada menciona sobre a questão da inclusão dos requerentes na SPE).

Prossegue a discussão apenas em dezembro de 2018 em que se tenta agora o penhor de cotas da SPE como garantia para a escritura de dação de unidades futuras (fls.110). E aqui nota-se o evidente impasse.

Não há como se prosseguir o projeto de incorporação sem a transferência do imóvel. Trata-se de exigência legal (art. 32, alínea "a" da lei 4591/64). Mas os requerentes, mesmo abandonando a discussão sobre suas inclusões na SPE desde maio de 2017 (ora invocado como obrigação inadimplida ensejadora da rescisão) pelo que se depreende dos autos (situação esta de contornos estritamente tributários, já que, como visto, a SPE visa afetar o patrimônio para garantia do comprador), não realizam referida transferência mas cobram a realização da obra.

A retomada da discussão de inclusão em dezembro de 2018, pelo i. Patrono que promove esta ação em nada altera a situação. Pelo contrário, a correspondência de fls. 114, em que se cobra a cópia do contrato social da SPE em que serão dadas em pagamento quotas as requerentes parece esquecer que em nenhum momento se estabeleceu valor de quotas, quantidade, sendo certo que o preço do imóvel pelo próprio contrato, não seria pago em quotas, mas sim parte em espécie (que foi recebida sem reclamação, e que sequer cogitam devolução) e parte em unidades futuras.

E daí se constata que a situação não pode ter solução diversa da improcedência. Prescreve o art. 113 do Código Civil que:

"Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;
II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;

III - corresponder à boa-fé;

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração".

Ora, percebe-se claramente que a intenção dos requerentes não é integrar a SPE, administrar a obra, ou mesmo gerir o empreendimento. Se assim não fosse não teriam concordado que todas as obrigações referentes a incorporação ficassem a cargo do comprador, como consta do compromisso de compra e venda e dação. Teriam exigido desde logo a quantificação de cotas e especialmente a inclusão das mesmas como integrantes do preço do imóvel. Tal não ocorre.

Mais ainda.

Mesmo não tendo sido incluídos na sociedade no final de 2016, conforme contratado, só questionaram a situação em abril do ano seguinte; e esclarecida a impossibilidade em maio do mesmo ano (o que foi revelado ao então Patrono dos requerentes, mas não trazido aos autos), mantiveram-se inertes desde então sempre buscando o atendimento de necessidades financeiras pontuais (demandas trabalhistas, problemas de saúde) no que foram prontamente atendidos. Mas mesmo com o recebimento de valores em pecúnia (expressivos) recusaram a outorga da escritura de forma a atender comando normativo e permitir a incorporação e o regular desenvolvimento do empreendimento (que demandava obviamente as autorizações junto ao órgão público competente).

Contata-se que, na verdade, os autores se acomodaram com a situação enquanto recebiam valores referentes ao empreendimento, e que não realizaram a transferência como forma de buscar mais benefícios.

Patente a questão da supressão no caso, inclusive em atenção a outros adquirentes de boa-fé, e ao fato de que sempre se denominaram parceiros no empreendimento, mas nunca assumiram efetivo risco da parceria. Quiseram, de forma prática e verdadeira, condicionar a entrega do terreno ao efetivo recebimento senão da maior parte, ao menos de valores pecuniários maiores que os efetivamente convencionados.

Em resumo, a boa-fé deve pautar o negócio. A interpretação sistemática do contrato e do entorno que envolveram as negociações, e as tratativas subsequentes ao aditamento comprovam que na verdade o que ocorreu foi uma compra e venda simples com pagamento direto de valores, e indireto por meio de unidades. A inclusão na SPE seria a princípio uma "garantia" (na verdade apresenta contornos de elisão fiscal); a partir do momento em que inviabilizada em maio de 2017 tornou-se em mecanismo de pressão para renegociação de condições, com transferências de obrigações pecuniárias, sobre o singelo argumento de retardamento de uma obra que não poderia iniciar sem a regular incorporação. E esta não poderia se realizar sem a transferência da propriedade. Conclui-se daí a ausência de efetiva boa-fé dos requerentes condutora a aplicação da supressão em relação a ausência de inclusão dos mesmos na SPE, o que inviabiliza a rescisão por tal fundamento.

E como a recusa desarrazoada da transferência do bem ao adquirente não há que se falar em retardamento de incorporação e das obras daí decorrentes, porque havia a necessidade de obtenção das autorizações necessárias. Logo, esterilizado tal argumento. Consequentemente, não se reconhece culpa, não se rescinde o pacto, ficando prejudicados os pedidos indenizatórios e os encargos penais.

Assim, precede a pretensão referente ao processo conexo para que os autores sejam obrigados a cumprir a obrigação assumida de outorgar a escritura para transferência do imóvel.

Isto posto, julgo improcedente o processo nº 1049024-39.2021.8.26.0100 e procedente o processo nº 1006132-09.2021.8.26.0006, extinguindo ambos os processos com análise do mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condene os autores/réus David e Miriam na obrigação de outorgar a escritura para transferência do imóvel a SPE a título de conferência de bens, na forma do contrato. Rejeitadas as demais pretensões na forma anteriormente exposta. Arcarão apenas eles com o pagamento das custas e despesas processuais e com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor de cada causa. Mantido o valor das causas para fins recursais. P.R.I.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

Helmer Augusto Toqueton Amaral
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA